

1501792-58.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501792-58.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501792-58.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137948/2020 - DEL.POL.CUBATÃO, 11761770 - DEL.POL.CUBATÃO, 538/20/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2137948 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DALMO PEREIRA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

I - RELATÓRIO

DALMO PEREIRA FILHO foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 03h07, na Avenida Nove de Abril, próximo ao nº 1845, Centro, Cubatão, DALMO PEREIRA FILHO, qualificado a fls. 27, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente, cocaína, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 06 e auto de constatação provisória de fls. 07. Segundo o apurado, na data e local dos fatos, durante patrulhamento, policiais militares visualizaram dois indivíduos saindo de um posto de combustível, após

utilizar o caixa eletrônico. Ao serem abordados, foi localizado, especificamente, com o denunciado, 16 "ependorfs" contendo, em seu interior, cocaína (25g - peso bruto). Ouvido formalmente confessou a prática delitiva, afirmando que adquiriu as drogas apreendidas, no valor de R\$10,00, cada, para serem revendidas, no valor de R\$20,00, cada (fls. 16). A razoável quantidade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, os testemunhos dos policiais e a confissão formal do denunciado, demonstrou que o mesmo praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2020 (fls. 80/92).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 138/140).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do delito de tráfico de drogas, e enquadramento no crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Ultrapassada essa questão prévia, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06), termo de depoimento (fls. 11, 14/15), relatório final (fls. 62/66), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório. Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciaria.

Vejamos:

Em solo policial, a testemunha WELLINGTON COSTA DOS SANTOS disse que “também é policial militar, sendo que nesta madrugada se encontrava em serviço de patrulhamento pelas ruas da cidade na companhia do Condutor CbPM Do Carmo, dirigindo-se com ele, por volta das 03h, até o posto de combustível no numeral 1845 da Av. Nove de Abril, no centro, posto que visualizou dois indivíduos que saíam do caixa eletrônico de lá; QUE, por lá foi abordado o indiciado Dalmo Pereira Filho, estando ele na posse de 16 (dezesseis) invólucros transparentes do tipo eppendorf contendo substância em pó branca e lhe acompanhando estava a testemunha Ricardo Carvalho Custódio Simões que nada trazia de irregular e de imediato afirmou que desconhecia o material encontrado com o indiciado Dalmo, tendo este confirmado: QUE, o indiciado Dalmo não trazia consigo qualquer dinheiro e ao ser perguntado sobre a droga, confessou que era para comercialização; QUE, diante dos fatos, o indiciado Dalmo e a testemunha Ricardo foram encaminhados até esta Delegacia, sem a necessidade do uso de força física” (fls. 14).

Em Juízo, disse que se recorda da ocorrência. No posto de gasolina Shell que fica nesta avenida visualizaram o Réu. Desconfiaram e efetuaram a abordagem. Encontraram uma sacola com drogas e uma quantia em dinheiro. O Réu disse que estava praticando o tráfico para sustentar seu próprio vício. O outro indivíduo encontrado juntamente com o Réu nada falou. Salvo engano eram uns 16-20 pinos de cocaína. O Réu confirmou que era para a mercancia. Não sabe dizer se foi coletada a assinatura do Réu no interrogatório policial.

Em solo policial, o condutor e testemunha MARCELO DO CARMO OLIVEIRA disse que “é policial militar, sendo que nesta madrugada fazia patrulhamento pelo município com a viatura I-21409, quando, por volta das 03h, passando pela Av. Nove de Abril, no Centro, visualizou dois indivíduos que saíam de um posto de combustível no numeral 1845, após o uso de caixa eletrônico; QUE, o depoente para lá se dirigiu, abordando o indiciado Dalmo Pereira Filho, em cujo poder foram encontrados 16 (dezesseis) invólucros transparentes do tipo eppendorf contendo substância em pó branca; QUE, a testemunha Ricardo Carvalho Custódio Simões que acompanhava o indiciado Dalmo nada trazia de irregular, tendo ela de imediato dito que desconhecia o material encontrado com ele, o que o indiciado Dalmo confirmou; QUE, em poder do indiciado Dalmo não fora encontrada qualquer quantia em dinheiro; QUE, o indiciado Dalmo, ao ser perguntado sobre a droga, confessou que era para comercialização; QUE, diante dos fatos, encaminhou o indiciado Dalmo e a testemunha Ricardo até esta Delegacia, sem a necessidade do uso de força física; QUE, aqui estando, e sido constatado que a substância se trata de cocaína, deu voz de prisão ao indiciado Dalmo” (fls. 11). Em Juízo reiterou a versão apresentada em fase inquisitiva, corroborando, inclusive, a versão apresentada por seu colega de farda sob o crivo do contraditório. A quantidade encontrada era cerca de 16 pinos de cocaína, embaladas para mercancia. Não sabe dizer a quantidade de droga que um usuário utilizada ao dia.

Em solo policial, a testemunha RICARDO CARVALHO CUSTODIO SIMÕES disse que “conhece, do mesmo bairro que o seu, o indiciado Dalmo Pereira Filho; QUE, o depoente se encontrava em um bar onde também se encontrava o indiciado Dalmo, o qual foi até sua mesa tomar uma bebida; QUE, em determinado momento o depoente se levantou para ir até o caixa eletrônico de um posto de combustível, tendo o indiciado Dalmo dito

que o acompanharia; QUE, na saída do posto houve a abordagem policial, sendo que em poder do indiciado Dalmo teria sido encontrada droga, a qual o depoente afirma que nem sabia da existência; QUE, nega fosse comprar a droga do indiciado Dalmo bem como ele não lhe ofereceu; QUE, o depoente e o indiciado Dalmo foram encaminhados a esta Delegacia, não tendo sofrido qualquer agressão física" (fls. 15). Em solo policial, o acusado DALMO PEREIRA FILHO disse que "fica ciente de que foram feitas várias tentativas para o telefone 13-3372 8766 a fim de comunicara sua mulher Sara, não se logrando êxito; QUE, neste ato não indica qualquer advogado para lhe acompanhar; QUE; o interrogado afirma que na manhã de ontem (sexta-feira) esteve em uma pracinha do bairro Jd. Costa Silva, onde adquiriu, de um indivíduo desconhecido que descreve como sendo homem branco, 1,75 de altura, sem barba e bigode, não usa óculos, com idade que não sabe informar; Que, a droga que foi apreendida no valor de R\$ 10,00 reais cada invólucro, sendo que revenderia cada um por R\$ 20,00 reais; Que, com relação a testemunha Ricardo Carvalho Custodio Simões há pouco tempo, mas nesta madrugada estava com ele em um bar bebendo, ocasião em que ele chamou para juntos irem a um caixa eletrônico em um posto de combustível na avenida Nove de Abril e na saída do posto houve a abordagem policial, encontrando-se em seu poder toda a droga apreendida; Que, veio confessar aos policiais que a droga era para comercialização; Que, o interrogado afirma que a testemunha Ricardo desconhecia que houve droga em seu poder; Que, afirma não ter sofrido qualquer tipo de agressão física ou moral por parte dos policiais responsáveis por sua prisão; Que, afirma estar recebendo auxílio por afastamento médico, mas mesmo assim continua fazendo "bicos" como pedreiro e pintor; Que, afirma ser viciado em álcool, especialmente cachaça, em maconha e crack; Que, perguntado sobre fato extraordinário, afirmou que deseja que sua família seja informada de sua prisão" (fls. 16).

Interrogado em Juízo, disse que no momento da abordagem não ofereceu droga para Ricardo. Não confessou em momento nenhum que estava vendendo drogas para os policiais. Disse apenas que era usuário de drogas para o Delegado. É usuário de drogas há bastante tempo, sempre parando ou voltando. É usuário de cocaína e álcool e, às vezes, crack. Não revenderia a droga apreendida. Na ocasião dos fatos estava sem dormir há uns 3 ou 4 dias. O Sr Ricardo não sabia de nenhuma droga apreendida. Foram até um caixa eletrônico para sacar dinheiro pois estavam num bar bebendo. Não se recorda quanta droga foi apreendida, salvo engano uns 15 ou 16 pinos. Não sabe dizer quantos pinos de cocaína utiliza quando começa a cheirar. Cada pino depende a quantidade de gramas. Não leu seu depoimento prestado em solo policial. Não conhecia os policiais que o abordaram. Também não conhecia o Delegado. Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, pois a versão apresentada pelo Réu não encontra eco no manancial probatório, quedando-se isolada.

Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem

pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, “a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficiente para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática do crime descrito na denúncia, não havendo,

portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos.

Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que o acusado, de forma deliberada, guardava e tinha em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 -, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprе ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar – que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de “guardar” é apenas umas das condutas que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, o acusado foi abordado em razão de uma investigação policial já instaurada há meses.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autora do acusado em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Adianto que, no caso em análise, é inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque o objetivo do aludido dispositivo de lei é privilegiar a figura comumente denominada por pequeno traficante ou traficante eventual, que pouco se dedica ao comércio espúrio e, quando o faz, realiza em pequena quantidade de drogas.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelo Réu. De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, “não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também

constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.^a ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes, em virtude da prática anterior há mais de 20 (vinte) anos da outra condenação (fls. 39). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria penal, existente a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.346/06. Embora não tenha comprovado ocupação lícita, não foi demonstrado durante a instrução criminal que estava se dedicando a atividades criminosas ou pertencia a organização criminosa – ônus que competia à acusação (art. 156 do CPP) -. Portanto, possível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11343/06, sob pena de se esvaziar por completo a aplicação da causa redutora e de violação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou a participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra in dubio pro reo" (STF, HC 103225-RN, 2ª T. rel. Min. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u). No mesmo sentido, também do c. STJ: HC 185331-RJ, 5ª T. rel. Min. Jorge Mussi, 14.02.2012, v.u).

Assim sendo, levando-se em consideração as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, diminuo a pena no patamar máximo de 2/3 (nesse sentido: STF comrepercussão geral no ARE 666.334, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06/05/2014).

Reprimenda definitiva, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto ausente informações acerca da situação econômica do Réu (art. 49, § 1º c/c art. 60 do CP).

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Por sua vez, com relação à almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16.02.2012, com

efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal. Nessa linha, insta consignar entendimento recentemente exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de julgamento do HC 118.533, por maioria de votos, decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06), por veemente desproporcional. Tendo em vista as condições pessoais do acusado e natureza do ilícito praticado, consoante acima observado, é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos - por igual período ao da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo de fática reclusão -, consistentes na prestação de serviços à comunidade (a ser definida pelo Juízo das Execuções) e à limitação de fins de semana, inexistindo razão impeditiva a tal. Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda imposta (art. 33, § 1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c"), frente ao quantum fixado e às condições pessoais do réu, aqui já consideradas.

VI - PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente. Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 06) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu DALMO PEREIRA FILHO, qualificado a fls. 27, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/06, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a-) prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução; e b-) limitação de finais de semana.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

Tratando-se de dinheiro e bens apreendido (fls. 06) em decorrência de tráfico de drogas, DECRETO O PERDIMENTO dos mesmos em favor da UNIÃO (art. 91 do CP, art. 63, § 1º da Lei 11.343/2006 e Provimento 20/2006-CGJ), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer "sem a necessidade de se perquirir a habitualidade,

reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito” (tema 647).

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila “acompanhamento de preventiva decretada”, para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Após o trânsito em julgado:

a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) intimem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);

c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);

d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;

e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.

f) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se caso.

g) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA